

N. R.G. 11936/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Susanna Terni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11936/2021** promossa da:

CP_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. CHECHILE MICAELA,
elettivamente domiciliata in VIA SAN LEONARDO, 161 84131 SALERNO presso il difensore avv.
CHECHILE MICAELA;

ATTRICE

contro

Controparte_2 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI IVAN,
elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO SALVINI, 5 20122 MILANO presso il difensore avv.
FOSSATI IVAN;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 22.12.2023

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 01.03.2021 CP_1 conveniva in giudizio CP_2
[...] assumendo di aver formalizzato, in data 28.03.2019, una proposta di acquisto di due unità
immobiliari site nel Comune di Milano, via Francesco Sforza n. 46, di proprietà della convenuta, con
pagamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di acconto, e successivamente, in data 18.06.2019,
contratto preliminare di compravendita dei suddetti immobili corrispondendo, contestualmente,
l'ulteriore importo di euro 150.000,00.

L'attrice proseguiva esponendo che in data 24.07.2019 aveva informato la convenuta di aver ceduto la propria posizione contrattuale a società terza, e la convenuta rifiutando di avallare la cessione, con missiva del 16.09.2019, aveva comunicato lo scioglimento del contratto per inadempimento imputabile alla promissaria acquirente, trattenendo le somme da questa corrisposte a titolo di acconto.

Chiedeva la restituzione degli importi versati (€ 15.000,00 + 150.000,00 = 165.000,00) e la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito per violazione del canone di buona fede nelle trattative; in via subordinata, la dichiarazione di efficacia del contratto preliminare stipulato *inter partes*, con assegnazione di un termine per il pagamento del residuo prezzo.

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta *Controparte_2* contestava la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto, nonché l'accertamento dell'avvenuto scioglimento del contratto preliminare per esercizio del diritto di recesso *ex art.1385 c.c.*, e della legittima ritenzione della caparra confirmatoria corrisposta dalla promissaria acquirente.

Al riguardo *Controparte_2* riferiva che parte attrice si era resa inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare in quanto non aveva provveduto al pagamento dell'ulteriore importo di euro 150.000,00 entro il termine fissato nel contratto preliminare e, pur sollecitata, aveva ommesso di comunicare il nominativo del notaio prescelto per il rogito, da sottoscrivere entro il termine essenziale del 30.07.2019; la medesima società promissaria acquirente aveva, inoltre, ceduto il contratto preliminare a società terza, prospettando una modifica delle condizioni contrattuali.

La convenuta riferiva quindi di aver chiaramente manifestato a controparte la propria volontà di non acconsentire alla cessione del contratto e di aver intenzione di dar seguito alla pattuizione con la contraente originaria; nondimeno, a fronte della persistente inerzia di *CP_1* in data 16.09.2019, per il tramite del proprio difensore, parte convenuta aveva quindi dichiarato di ritenersi libera da qualsivoglia obbligo contrattuale.

Secondo la convenuta il contratto preliminare si era quindi sciolto per effetto dell'esercizio del recesso *ex art. 1385, co. II, c.c.* conseguente all'inadempimento di *CP_1* per violazione del termine essenziale e la caparra confirmatoria corrisposta dalla promissaria acquirente, pari a complessivi euro 165.000,00, sarebbe stata legittimamente trattenuta.

Da ultimo, parte convenuta dava conto che, comunque, il compendio immobiliare oggetto del contratto preliminare era stato in seguito alienato a terzi.

Depositare le memorie ex art.183, VI co., c.p.c, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nel verbale di udienza a trattazione scritta del 22.12.2022 , previa concessione dei termini *ex* art.190 c.p.c.

L'odierna controversia concerne il rapporto contrattuale instauratosi *inter partes*, finalizzato alla compravendita di due unità immobiliari di proprietà dell'odierna convenuta. In specie, risulta agli atti che nel marzo del 2019 quest'ultima si è impegnata ad acquistare il compendio immobiliare corrispondendo la somma di euro 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria al momento della accettazione della proposta. In data 18.06.2019, le parti hanno quindi sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con contestuale versamento, da parte della promissaria acquirente, di euro 150.000,00 a titolo di ulteriore caparra confirmatoria da imputare al prezzo di vendita ai sensi dell'art. 1385 c.c.

In forza della convenzione sottoscritta, il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30.07.2019, previo pagamento da parte della promissaria acquirente di un ulteriore importo (pari euro 150.000,00), a titolo di caparra confirmatoria, entro il 25.07.2019 (cfr. art. 4 del contratto preliminare). La compravendita non si è però perfezionata in quanto, pochi giorni prima della scadenza del termine, **CP_1** ha comunicato a controparte di aver ceduto la propria posizione contrattuale a società terza, con la quale la promittente venditrice avrebbe quindi dovuto stabilire nuove condizioni di pagamento. **Controparte_2** ha rifiutato di riconoscere la predetta cessione, chiarendo di non aver intenzione di trattare con la cessionaria e di voler dar seguito alla pattuizione come concordata con l'originaria contraente. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione del definitivo, in data 16.09.2019, **Controparte_2** ha comunicato lo scioglimento del contratto preliminare a causa dell'inadempimento imputabile a controparte.

Secondo la prospettazione di parte attrice tale contegno integra una violazione del canone di buona fede, fonte di responsabilità precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative.

Al riguardo osserva questo Giudice che, pur inserendosi nell'ambito di un rapporto a formazione progressiva, il contratto preliminare esaurisce la fase della negoziazione, trattandosi di una pattuizione con effetti pienamente vincolanti per le parti, alla stregua di un qualsiasi altro contratto.

Dunque, il diniego prestato dalla convenuta alla rimodulazione delle condizioni contrattuali si colloca in un momento in cui le parti si erano già giuridicamente vincolate alla stipulazione della

compravendita, sicché non può evidentemente configurarsi alcun abbandono delle trattative, ormai già concluse.

In ogni caso, il principio di buona fede oggettiva, ricavabile dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost., permea il rapporto contrattuale in tutto il suo svolgimento, dalla formazione alla esecuzione, richiamando le parti ad una reciproca lealtà di condotta. Pur nella sua ampiezza, il principio di correttezza e solidarietà non deve però essere inteso in senso assoluto, come obbligo di acconsentire ad ogni richiesta proveniente dalla controparte; più precisamente, esso impone alle parti di esercitare i propri diritti nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, evitando comportamenti vessatori, non sorretti da un interesse giustificativo e, quindi, inutilmente pregiudizievoli delle esigenze altrui.

Così circoscritto il perimetro della buona fede, non può imputarsi alla promittente venditrice alcun comportamento scorretto. Infatti, Controparte_2 rifiutando di avallare la cessione del contratto, ha legittimamente esercitato la propria autonomia negoziale al fine di tutelare le proprie ragioni di credito, anche in considerazione della necessità di estinguere celermente il mutuo dalla stessa contratto in vista dell'operazione immobiliare. Non emerge, invece, alcun intento abusivo o emulativo della convenuta, tanto più che la cessione le è stata comunicata a ridosso della data fissata per la conclusione del contratto definitivo e in assenza di una idonea garanzia di solvibilità della società cessionaria, di recentissima costituzione.

Del resto, difetta una norma di legge che sancisca il diritto/dovere di rinegoziare il contratto su richiesta della controparte; tantomeno, tale dovere può farsi discendere dal contratto stipulato *inter partes* e, in particolare, dalla clausola invocata da parte attrice, di cui all'art. 12.2 del contratto preliminare, che così recita: *“Qualora alcuna delle previsioni del presente contratto sua o divenga nulla, contraria alla legge o non eseguibile ai sensi della legge applicabile, non verrà inficiata o pregiudicata, in alcun modo, la validità, la conformità alla legge o l'eseguibilità delle restanti previsioni. Le Parti condurranno, in buona fede, negoziazioni al fine di concordare i termini di una previsione in sostituzione della previsione risultata nulla o non eseguibile, che sia soddisfacente per entrambe e che consegua, per quanto possibile, il medesimo effetto commerciale”*.

L'attrice sembra fornire una interpretazione della disposizione contrattuale che va ben al di là del significato fatto palese dalle parole impiegate. La clausola, infatti, risulta chiaramente preordinata a salvaguardare l'efficacia del contratto in ipotesi eccezionali di sopravvenienze che comportino l'invalidità o l'oggettiva impossibilità di esecuzione di alcune sue previsioni, richiamando le parti a

trattare in buona fede in vista della manutenzione del contratto. Di contro, non emerge affatto che le parti si siano volute obbligare a rinegoziare il contratto sulla base della semplice richiesta della controparte che, come in questo caso, adduca la propria difficoltà ad adempiere alle condizioni originariamente pattuite, senza peraltro nulla dedurre o allegare in relazione alla asserita non eseguibilità della prestazione, se non con generico riferimento alla congiuntura economica.

In definitiva, anche alla luce di queste considerazioni, la domanda svolta in via principale da parte attrice non può trovare accoglimento.

Quanto alla richiesta subordinata di dichiarare efficace il contratto preliminare con fissazione del termine per il pagamento del prezzo, la domanda risulta inammissibile. Infatti, in caso di inadempimento dell'obbligo di contrarre contenuto nel preliminare, la parte non inadempiente ha la possibilità di richiedere la risoluzione, secondo le norme ordinarie, ovvero attivare il rimedio *ex art. 2932 c.c.*, al fine di ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso. Di contro, non trova alcun appiglio normativo la domanda di accertamento svolta da *CP_1* [...] il cui accoglimento non produrrebbe alcun effetto utile, non essendo in dubbio l'effettiva stipulazione del contratto preliminare.

Peraltro, anche volendo ricondurre le conclusioni formulate da parte attrice nell'alveo dell'azione di esecuzione in forma specifica *ex art. 2932 c.c.*, non sussistono i presupposti per l'emissione di detta pronuncia, attesa l'impossibilità giuridica di giungere a una sentenza traslativa che si sostituisca al contratto definitivo non concluso. Infatti, risulta agli atti che il compendio immobiliare è stato definitivamente alienato da *Controparte_2* a soggetto terzo con contratto stipulato il 30.01.2020 e regolarmente trascritto (cfr. doc. 12 del fascicolo di parte convenuta).

Invero, l'esecuzione del contratto preliminare sottoscritto *inter partes* è preclusa anche perché la pattuizione risulta, ormai da tempo, irreversibilmente caducata per effetto del recesso esercitato dalla promittente venditrice ai sensi dell'art. 1385, co. II, c.c.

La norma configura uno speciale strumento di risoluzione per giusta causa, collegato ad un inadempimento avente i medesimi caratteri di quello che giustifica la risoluzione¹.

¹ Si veda Cass. ord. n. 21209 del 2019: "*La disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c. in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente; ne consegue che il giudice è tenuto ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio*".

In tale frangente, la giurisprudenza ha affermato la reciproca fungibilità tra risoluzione e recesso, valorizzando la comunanza di presupposti (l'inadempimento della controparte) e conseguenze (la caducazione degli effetti del contratto)² dei due istituti.

Ne consegue che, anche in ipotesi di inosservanza del termine essenziale, la parte non inadempiente, anziché avvalersi della risoluzione *ex art. 1457 c.c.*, può scegliere di agire per la ritenzione della caparra confirmatoria, in una sorta di azione risarcitoria semplificata rispetto a quella ordinaria, con limitazione forfettaria del danno. Infatti *“la risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (art. 1457 cod. civ.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 cod. civ. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa; in tal caso, però, si può considerare legittimo il recesso solo quando l'inadempimento dell'altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del recedente³.”*

Nell'odierno giudizio risulta che le parti, convenendo di concludere il contratto definitivo entro il 30.07.2019, abbiano individuato un termine essenziale. In tal senso depone l'inequivoca espressione utilizzata dai contraenti, che si riferisce in modo diretto alla rilevanza della data come limite invalicabile per concludere il contratto definitivo; l'improrogabilità del termine è stata, peraltro, sottolineata dalla venditrice nella interlocuzione con la controparte (si veda doc. 8 parte convenuta).

Dunque, in violazione del vincolo obbligatorio risultante del contratto preliminare, la promissaria acquirente non ha convocato la società venditrice per la firma del rogito di compravendita entro il termine suindicato. L'inadempimento è indubbiamente grave atteso che, con la persistente inerzia nonostante l'invito della promittente venditrice a fissare la data del rogito, **CP_1** ha fatto mancare la prestazione di quell'attività intrinsecamente necessaria per il perfezionamento della compravendita, disattendendo in radice l'obbligazione tipica del contratto preliminare, ossia la prestazione del consenso per la stipulazione del contratto definitivo.

Tale inadempimento, segnato dallo sforamento temporale rispetto al termine essenziale, è maggiormente aggravato dalla circostanza che la promissaria acquirente ha altresì omesso di versare l'ultimo importo imputabile a titolo di caparra confirmatoria entro il termine individuato parimenti

² Cass., Sez. Un., n. 553 del 2009.

³ Cfr. Cass. n. 21838 del 2010; in termini anche Cass. n. 14014 del 2017.

come essenziale dal contratto (25.07.2019); la società, inoltre, ha chiaramente palesato la volontà di non addivenire alla stipula del definitivo quando, a pochi giorni dalla scadenza del termine, ha comunicato di voler cedere l'affare ad altra società, pur senza il necessario assenso della controparte. Ebbene, a fronte di un siffatto inadempimento è legittimo l'esercizio del diritto di recesso operato da **Controparte_2** quando, il 16.09.2019, ha comunicato alla promissaria acquirente di sentirsi libera da qualsivoglia vincolo contrattuale a causa del suo comportamento. In proposito è opportuno precisare che il diritto di recesso non è soggetto a formalità particolari, in quanto è destinato a divenire operante con la semplice manifestazione di una volontà caducatoria degli effetti negoziali⁴.

Allo scioglimento del contratto è correlato il diritto di ritenzione della caparra confirmatoria, secondo quanto previsto dall'art. 1385, co. II ,c.c; infatti, la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione *ope legis* di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso; ovvero chiedere la risoluzione del contratto, secondo le norme ordinarie, ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare ai sensi dell'art. 1223 c.c.⁵.

Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento della domanda prospettata dalla convenuta, deve dichiararsi la legittimità del recesso esercitato dalla promittente venditrice e, conseguentemente, il suo diritto a ritenere la caparra confirmatoria corrisposta dalla promissaria acquirente, per un ammontare complessivo di euro 165.000,00.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14 nello scaglione di riferimento da euro 52.000 ad euro 260.000 nella somma di euro 11.268,00 (fase istruttoria dimidiata).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande di parte attrice;
- accerta e dichiara la legittimità del diritto di recesso esercitato da parte di **Controparte_2** dal contratto preliminare stipulato con **CP_1** il 18.06.2019 e per l'effetto, il diritto di Grande

⁴ Cass. n. 5095 del 2015.

⁵ In tal senso, Cass. n. 18850 del 2004.

CP_2 di ritenere la caparra confirmatoria corrisposta da *CP_1* pari a complessivi euro 165.000,00;

- condanna *CP_1* alla refusione in favore di *Controparte_2* delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e CPA.

Milano, 23 marzo 2023

Il Giudice
Susanna Terni